

1502259-20.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... uma vez que relacionados com o tráfico ilícito de drogas. Determino a perda do dinheiro apreendido, uma vez que está relacionado com o tráfico ilícito, procedendo-se a transferência para o fundo nacional criado por lei para este fim. Também, determino a destruição dos demais bens apreendidos porque estão relacionados com o tráfico ilícito de drogas. O julgamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502259-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502259-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANILO XAVIER DA SILVA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 22 de Fevereiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o acusado; DANILO XAVIER DA SILVA, preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para

apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito: Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo a que foram submetidas as substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia a qual é recebida nesta data. O acusado é citado por vídeo conferência e diante da sua presença nesta data, por economia processual, já fica intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas, policiais militares, Leonardo Rodrigues Aires e Jose Antônio de Souza Gomes. Na sequência, pela ordem, pelo Ministério Público foi pedido o aditamento da denúncia em face das informações trazidas pelos policiais, nos seguintes termos: MM Juiz, Diante da prova oral colhida nesta data e, em consulta ao aplicativo do google maps que confirma que o local dos fatos era próximo a estabelecimento de ensino e estabelecimento onde se realizam atividades recreativas (parque) adito a inicial acusatória a fim de inserir no primeiro parágrafo que o local estava nas imediações de estabelecimento de ensino e de recreação e para que no último parágrafo o réu seja denunciado como incurso no art. 33 caput c.c. art 40, III da lei 11.343/06 c.c. art. 61, II, j do CP, mantidos os demais termos da denúncia. A acusação encaminhou fotografia do local pelo sistema google maps onde se visualiza claramente a presença do parque linear cantinho do céu e CEU CEI Navegantes além de outro estabelecimento de ensino mencionado pelas testemunhas nesta data. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Presentes os requisitos legais, dava vistas para a defesa se manifestar sobre o aditamento, bem como dava a ciência ao acusado sobre os termos. Na sequência pela defesa foi dito que reiterava os termos da defesa preliminar e se reservava a momento oportuno para discutir o mérito. Pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Recebo o aditamento da denúncia, uma vez que presentes os requisitos legais. O réu acompanhou o presente ato e foi informado pelo juízo sobre o conteúdo do aditamento. Considerando que não foram requeridas novas provas, além do que o réu está ciente da denúncia e do seu aditamento, passava ao seu interrogatório após o mesmo conversar com o seu defensor em particular, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, O réu DANILO XAVIER DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (aditada em audiência), porque, no contexto descrito na denúncia, em plena pandemia de coronavírus (COVID 19), em local próximo a estabelecimento de ensino e estabelecimento onde se realizam atividades recreativas (parque), conforme exposto por ocasião do aditamento da denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com ao menos outro indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para fins de venda e entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 12 invólucros contendo 2,5g (duas gramas e cinco decigramas) de cocaína; 25 invólucros contendo 185,9g (cento e oitenta e cinco gramas e nove decigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha; 18 frascos contendo 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), na forma de skunk; 07 frascos contendo

66,5ml (sessenta e seis mililitros e meio) de tricloroetileno, vulgarmente conhecido como lança-perfume; 04 invólucros contendo 1,7g (uma grama e sete decigramas) aparentemente de ecstasy, cuja natureza será confirmada no exame químico-toxicológico; 08 frascos contendo 0,056g (cinquenta e seis miligramas) de substância aparentando tratar-se da droga sintética K2, cuja natureza será confirmada no exame químico-toxicológico, além de um pé de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 99,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, fotografia de fls. 28, laudo de constatação de fls. 20/27 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regulamente recebida. O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, B.O de fls.29/32, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, bem como pelo laudo de constatação de fls. 20/27 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls. 154/157, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogados, o réu reservou-se ao direito de permanecer calado (fls.15). Em juízo, o réu negou a acusação. A negativa do réu não convence e restou totalmente isolada das demais provas. Vejamos. Ouvida na fase inquisitiva o policial JOSÉ ANTÔNIO narrou a fls.07 que efetuavam patrulhamento quando visualizaram dois indivíduos que, ao avistar a viatura, se evadiram, sendo que um deles jogou uma bolsa laranja que trazia consigo no chão. Após perseguição, conseguiram deter o indivíduo que havia jogado a bolsa, posteriormente identificado como DANILO. No interior da bolsa foram localizados os entorpecentes supramencionados, bem como a quantia de R\$113,00 (cento e treze reais) em notas trocadas. Em seguida, localizaram, no local da abordagem, conhecido ponto de venda de drogas, um pé que planta semelhante à maconha. Diante disso, o réu foi preso em flagrante. Nestes exatos termos foi o depoimento do policial LEONARDO a fls. 08 em solo policial. Em juízo, o policial JOSÉ ANTONIO narrou que não conhecia o réu antes dos fatos. Estavam em patrulhamento próximo ao local, onde tem um parque que as crianças brincam no final da tarde. Próximo tem um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes. Visualizaram dois rapazes que, ao verem a equipe, saíram. Um deles estava com uma mochila nas mãos, ele correu e jogou a bolsa. Seu colega correu atrás dele e conseguiu abordá-lo. O depoente pegou a mochila dispensada. Danilo foi levado até a bolsa e ao abrir constataram o ilícito dentro da bolsa. Foi constatado também que havia um pé de maconha. Dentro da mochila havia uma quantia em dinheiro, R\$ 113,00. Tinha bastante droga, até comprimidos, ecstasy ou K2, umas drogas que nunca havia visto. As drogas estavam num saquinho prontas para a comercialização. Cerca de 500 metros do local, havia uma escola. Mas, não se recorda se estava funcionando, mas no parquinho havia crianças. No dia, havia pessoas e crianças no parquinho. No mesmo sentido, o depoimento do policial LEONARDO em juízo, que também confirmou que havia um parque ali próximo com crianças etc e os demais termos de seu colega de farda. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão, quantidade e variedade de drogas e a apreensão de dinheiro e notas trocadas, evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as

testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico “recebimento com ressalvas” do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho... Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: “O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos” (TJSP – AC 205162-3/4 – Rel. Jarbas Mazzoni – RT733/566).

Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da variedade e expressiva quantidade de estupefacientes, frisando-se que havia inclusive causa sintética, nos termos do art. 59 do CP. Já na segunda fase, observo a agravante da calamidade pública do art. 61, II, “j” do CP. Finalmente, na terceira e derradeira fase, não verifico causa de diminuição de pena, mas sim, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da lei de drogas, eis que os fatos foram praticados próximo a estabelecimento de ensino (2) e de recreação (parque) tanto que os policiais foram claros ao dizer que ao efetuar a prisão do réu pessoas que estavam no parque saíram para olhar. Ademais, os fatos ocorreram em quarta feira num período da tarde em que as escolas já haviam retornado suas atividades. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado. Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de “graça, anistia e fiança”, relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por “hediondos” – seja na sua forma tentada ou consumada –, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela

Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda “lavar” o dinheiro obtido, depositando-o na conta de “laranjas” fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes dissecar todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), “a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Não há dúvidas, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, DANILO XAVIER DA SILVA está denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a denúncia aditada para inclusão de causa de aumento (artigo 40, III, da Lei de Drogas). Em instrução probatória oral foram ouvidos apenas e tão somente os policiais responsáveis pela prisão do réu, com derradeiro interrogatório do réu. Ao término disso, em que pesem as ponderações do nobre representante ministerial, a Defesa aponta se tratar de caso de ABSOLVIÇÃO. Os policiais aduziram que estavam em patrulhamento, sendo que viram o réu junto com um terceiro. O réu teria dispensado a mochila e tentado se evadir com o terceiro não identificado. Somente o réu foi detido e encontradas drogas e dinheiro na mochila. O réu negou a prática dos fatos. Aduziu que estava no local para comprar drogas para uso próprio. Pois bem, Excelência, PRELIMINARMENTE, observa-se que as provas devem ser declaradas ilícitas por outro motivo. Com efeito, restou evidente a violação ao disposto no art. 158-B do CPP no sentido de que é necessário o rastreamento do vestígio em etapas que não foram observadas. Ora, o inciso II informa que o local deveria ter sido isolado, ou seja, quando os policiais supostamente encontraram as drogas na posse do indiciado, deveriam ter isolado o local; além disso, o art. 158-C, em seu §2º, informa a proibição de entrada nos locais isolados antes da liberação por perito. Aqui, o local não foi isolado e não houve comparecimento de qualquer perito, conforme

se extrai do boletim de ocorrência e dos depoimentos. Na sequência, seria necessária a descrição detalhada do vestígio, exatamente da maneira como encontrado, e seria indispensável a descrição no laudo oficial, ou seja, o perito oficial deveria ter comparecido ao local dos fatos ou, no mínimo, os policiais deveriam ter fotografado a cena (inciso III). As demais exigências legais – fase de coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte – incisos IV a X –consequentemente, restaram comprometidas já que o que aconteceu, pelo que se extrai dos autos, foi o transporte da droga na própria viatura, sem a observância dos ditames legais. Pode ter havido, no meio do caminho, algum erro, troca ou desvio, não existindo segurança nesta questão. Observa-se que a prova da materialidade, aqui, está longe de ser inquestionável porque, inclusive,

não existe a documentação exigida pelo inciso VII do art. 158-B do CPP: não há código de rastreamento, não há protocolo de recebimento da droga e, menos ainda, a devida identificação de quem a recebeu. Assim, não havendo prova da materialidade do delito, de rigor a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, II, do Código Penal. No mérito, quanto ao delito de tráfico de drogas, o réu merece ser absolvido. Não há provas que comprovem que o réu praticasse o tráfico. Não foram ouvidas outras testemunhas, que fossem isentas, e que presenciaram os fatos. Embora as testemunhas de defesa não tenham presenciado os fatos, narraram que o réu trabalha no lava-rápido, ou seja, tem atividade lícita, razão pela qual as palavras de inocência do réu não foram infirmadas nos autos. Ademais, é possível, no início do depoimento da primeira testemunha, verificar que a segunda testemunha já estava dentro da viatura de dentro da qual os depoimentos foram prestados, razão pela qual as palavras do da segunda testemunha não devem ser consideradas em desfavor do réu, já que tinha visto o depoimento anterior em violação ao princípio da confidencialidade. Compulsando os autos, assim, verifica-se que não existe prova segura para fundamentar a condenação. POSTO ISSO, REQUER A DEFESA SEJAM OS RÉUS ABSOLVIDOS PELA FLAGRANTE FRAGILIDADE DA PROVA, CONSOANTE O ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: requer-se a) fixação da pena base no mínimo legal, eis que o réu é primário e a quantidade de drogas não é de tal monta que autorize a exasperação da pena base, o afastamento da agravante relativa ao cometimento de delito durante a pandemia, eis que não há relação de causa e efeito entre o estado de pandemia e o cometimento do delito, não seja reconhecida a causa de aumento, eis que a Rua Porto Seguro, nº 24, via em que o réu teria sido encontrado, não restou pela prova produzida localizada de forma precisa, não se podendo afirmar que havia escolas ou atividades de recreação em local próximo. Ademais, não restou comprovado que o tráfico fosse dirigido a crianças ou adolescentes. Por fim, requer-se a aplicação da causa de diminuição relativa ao artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, levando-se em consideração a quantidade de drogas para efetuar a diminuição entre um e dois terços, tendo em vista que o réu preenche os requisitos legais, destacando a primariedade, ausente prova de ligação direta dos réus com organização criminosa; b) fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e c) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. DANILO XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 18h55min, durante período de calamidade pública (COVID-19), na Rua Francisco Inácio Solano, nº 650, Grajaú, nesta cidade de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com ao menos outro indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para fins de venda e entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 12 invólucros contendo 2,5g (duas gramas e cinco decigramas) de Cocaína; 25 invólucros contendo 185,9g (cento e oitenta e cinco gramas e nove decigramas) de Maconha, presente o princípio ativo Tetrahydrocannabinol (THC); 18 frascos contendo 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) de Skunk, presente o princípio ativo Tetrahydrocannabinol (THC); 07 frascos contendo 66,5ml (sessenta e seis mililitros e meio) de Tricloroetileno, vulgarmente conhecido como lança-perfume; 04 invólucros contendo 1,7g (uma grama e sete decigramas) aparentemente de Ecstasy, cuja natureza será confirmada no exame químico-toxicológico; 08 frascos contendo 0,056g (cinquenta e seis miligramas) de substância aparentando tratar-se da droga sintética K2, cuja natureza será confirmada no exame químico-toxicológico, além de um pé de Maconha, presente o princípio ativo Tetrahydrocannabinol (THC), pesando 99,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, fotografia de fls. 28, laudo de constatação de fls. 20/27 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, oportunidade em que foi preso por policiais militares que realizavam policiamento de rotina pelo local. A prisão

preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 22 de fevereiro de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como foi interrogado o réu. A denúncia foi aditada para acrescentar a imputação do aumento de pena de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, uma vez que o crime teria ocorrido em local próximo de unidade de ensino. O laudo químico toxicológico definitivo foi apresentado nos autos (fls. 154/157). Em sede de debates, a acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido.

I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia da prova foi mantida no presente feito, considerando a natureza do crime e as peculiaridades referentes ao local dos fatos e aos demais elementos da ocorrência policial. II. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Não cabe o benefício de não persecução penal porque o réu não confessou o crime na fase policial e se trata de ato privativo do Ministério Público. III. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. IV. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 154/157), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram “Cocaína”, “Maconha” (cannabis sativa L), Skunk, bem como que estava presente o princípio ativo responsável pelos seus efeitos entorpecentes (THETRAHIDROCANNABINOL), Tricloroetileno, vulgarmente conhecido como lança-perfume; Ecstasy, e a droga sintética K2. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram drogas proibidas, a materialidade do crime está provada. VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, , a condenação parcial é de rigor. Necessário consignar que existe uma diferença entre o tráfico de drogas no varejo e no atacado, uma vez que os criminosos que atuam no atacado carregam, normalmente, drogas em peças maiores e ainda não divididas ou misturadas conforme o caso. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 18h55min, durante período de calamidade pública (COVID-19), na Rua Francisco Inácio Solano, nº 650, Grajaú, nesta cidade de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com ao menos outro indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para fins de venda e entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 12 invólucros contendo 2,5g (duas gramas e cinco decigramas) de Cocaína; 25 invólucros contendo 185,9g (cento e oitenta e cinco gramas e nove decigramas) de Maconha, presente o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC); 18 frascos contendo 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) de Skunk, presente o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC); 07 frascos contendo 66,5ml (sessenta e seis mililitros e meio) de Tricloroetileno, vulgarmente conhecido como lança-perfume; 04 invólucros contendo 1,7g (uma grama e sete decigramas) aparentemente de Ecstasy, cuja natureza será confirmada no exame químico-toxicológico; 08 frascos contendo 0,056g (cinquenta e seis miligramas) de

substância aparentando tratar-se da droga sintética K2, cuja natureza será confirmada no exame químico-toxicológico, além de um pé de Maconha, presente o princípio ativo Tetrahydrocannabinol (THC), pesando 99,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, fotografia de fl. 28, laudo de constatação de fls. 20/27 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, oportunidade em que foi preso por policiais militares que realizavam policiamento de rotina pelo local. O acusado também estava na posse de valores relativos ao tráfico de drogas e descrito no auto de exibição e de apreensão. Ao ser ouvido, o réu fez uso do direito de permanecer calado na fase policial. Posteriormente, ao ser interrogado, o acusado negou a prática do crime e disse que estava saindo da casa da sua mulher quando foi preso e acusado indevidamente pela prática de crime que não praticou e apenas por causa dos seus antecedentes. Os policiais militares responsáveis pela prisão informaram que estavam realizando policiamento de rotina em um ponto conhecido como de venda de drogas, momento em que observaram o acusado e outra pessoa em situação típica de traficância. Inclusive, o acusado carregava com ele uma sacola e se desfez dela para fugir. Porém, segundo os policiais, o réu foi perseguido e preso, bem como apreendido dentro da sacola grande quantidade e variedade de drogas para o comércio ilícito de varejo. Os policiais ainda disseram que os fatos ocorreram em uma Comunidade e próximo de uma escola. Porém, não estabeleceram que a traficância visava crianças e adolescentes. Portanto, respeitosamente, não há dúvidas de que o réu estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas na modalidade do varejo, sendo certo que pela quantidade de drogas e variedade, dificilmente estaria sendo preso e acusado injustamente. Anota-se que sequer os policiais conheciam o acusado e sequer ele possui antecedentes criminais, haja vista ter sido absolvido com relação à imputação anterior de tráfico ilícito de drogas (fl. 37). Todavia, respeitosamente, tratando-se de uma Comunidade, com espaços reduzidos e sem a comprovação de que o tráfico visava o estabelecimento de ensino, bem como crianças e adolescentes, entendo que o conjunto probatório não é seguro para o reconhecimento da causa de aumento de pena aplicada. O dinheiro apreendido está relacionado com o tráfico de drogas, motivo pelo qual determino o seu perdimento. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. VII. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, considerando a quantidade e variedade de drogas traficadas, o que demonstra culpabilidade diferenciada, as penas básicas são majoradas em 1/5, passando para 06 anos de reclusão e 600 dias multa. Na segunda fase, considerando a agravante da prática do crime em momento de calamidade pública decretada pelo governador do Estado de São Paulo, sem mencionar o fato de que a situação de pandemia aumentou o consumo de drogas e o próprio tráfico ilícito de entorpecentes, conforme se observa pelo aumento das estatísticas policiais e pelos comentários veiculados pela imprensa, tudo a indicar a necessidade da majoração das penas básicas em 1/6 em face da agravante, passando as sanções para 07 anos de reclusão e 700 dias multa. Na terceira fase da aplicação da pena, não existindo provas de que o réu está integrado ao crime organizado, podendo ser mero autônomo pagando suas dívidas ou tentando conseguir meio de sobrevivência, sem me olvidar do posicionamento do STJ no sentido de que o aumento da pena base pela quantidade de drogas não pode ser repetido para o afastamento do privilégio, as penas são reduzidas em 2/3, passando para 2 anos e 4 meses de reclusão, e 233 dias multa, considerando o redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto e poderá recorrer em liberdade, conforme entendimento dominante no STJ. Não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial já ser o aberto. Ante o exposto, julgo PARCIAL PROCEDENTE, a ação penal para após a absolvição com relação ao artigo 40, inciso VI, ambo da Lei Federal nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenar

DANILO XAVIER DA SILVA, RG/SP nº 52.020.635, nascido em 31/08/1999, filho de Creuza Xavier da Silva, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 233 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Condene o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Presentes os requisitos do artigo 44 e s.s. do Código Penal, mormente diante da jurisprudência do STJ, substituo a pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos consistente na prestação e serviços para a comunidade em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais e pelo tempo da prisão preventiva. Também, por 10 dias multa no valor mínimo unitário legal a se somar à pena pecuniária. Oficie-se para a destruição dos entorpecentes guardados para contraprovas, uma vez que já há laudo definitivo e não houve impugnação. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos e guardados, uma vez que relacionados com o tráfico ilícito de drogas. Determino a perda do dinheiro apreendido, uma vez que está relacionado com o tráfico ilícito, procedendo-se a transferência para o fundo nacional criado por lei para este fim. Também, determino a destruição dos demais bens apreendidos porque estão relacionados com o tráfico ilícito de drogas. O julgamento está ocorrendo às 18 horas e 34 minutos, motivo pelo qual o alvará de soltura deverá ser expedido no dia seguinte em face do horário de funcionamento do Poder Judiciário conforme provimento. Publicada a sentença após o término da audiência, pelo MM Juiz foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e o réu para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nada mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital